

<제02장 근로관계의 성립.제03절 근로계약과 근로관계>

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출]11[2016-2]시용기간 만료 시 본채용 거부의 해고 여부 및 구두 통보의 정당성

《【문제2】 상시 근로자 300인을 사용하는 C회사는 시용기간을 2016. 1. 1. 부터 같은 해 6. 30. 까지로 정하여 근로자 乙을 채용하였다. C회사는 시용기간 만료 3일 전에 업무적격성이 없다는 이유로 乙에게 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보하였다. C회사가 乙에게 시용기간 만료 3일 전에 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 것이 정당한지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 시용기간 만료 시 본채용 거부의 해고 여부 및 구두 통보의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 C회사가 시용근로자인 乙에 대하여 시용기간 만료 전에 업무적격성 부족을 이유로 본계약 체결을 거절하면서 구두로 통보한 경우이다. 쟁점으로 <시용기간 만료에 따른 본계약 체결 거절의 법적 성질이 근로기준법상 해고에 해당하는지>, <근로기준법 제27조의 해고사유 서면통지 의무가 엄격하게 적용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 C회사 조치의 정당성 여부를 설명한다.

II. 시용근로관계와 본근로계약 체결 거절의 법적 성질 및 절차적 요건

1. 본채용 거절의 법적 성질

(1) 시용근로관계의 의의

- 시용이란 정식 채용을 하기 전에 일정 기간 동안 근로자의 업무능력, 성실성, 자질 등 업무적격성을 관찰하고 평가하기 위해 시험적으로 고용하는 근로관계를 말한다. 이는 사용자에게 해약권이 유보된 근로계약의 성격을 지닌다.

(2) 본계약 체결 거절의 해고성

- “대법원”은 시용기간 만료 시 본 근로계약 체결을 거절하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 실질상 해고에 해당하므로, 근로기준법상 해고 제한에 관한 규정이 전면적으로 준용된다고 판시한다.

2. 해고사유 서면통지의무의 적용 여부

(1) 근로기준법 제27조의 규정 취지

- “근로기준법 제27조”에 의하면 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면통지를 결여한 해고는 효력이 없다. 이는 사용자로 하여금 해고를 신중하게 결정하도록 유도하고, 해고의 존부와 사유를 명확히 하여 근로자가 이에 대처할 수 있도록 보장하기 위함이다.

(2) 시용근로자에 대한 서면통지 의무

- “대법원”은 시용근로관계에서 본 근로계약 체결을 거절하는 경우에도 “근로기준법 제27조”가 그대로 적용되므로, 사용자는 근로자에게 거절사유를 파악하여 대처할 수 있도록 구체적·실질적인 거절사유를 서면으로 통지하여야 한다고 판시한다. 따라서 서면통지 의무를 위반한 거절 통보는 사법상 효력이 부정된다.

III. 사안의 적용

1. 乙의 시용근로자 지위 및 본계약 거절의 해고성

- 乙은 시용기간이 2016. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지로 약정된 시용근로자에 해당한다. C회사가 乙에 대하여 업무적격성 부족을 이유로 본 근로계약 체결을 거절한 행위는 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 실질적인 근로기준법상 해고에 해당하는 처분이다.

2. 구두 통보의 법적 효력 및 정당성 여부

- C회사는 乙에게 본계약 체결 거절을 통보하면서 해고사유와 해고시기를 기재한 서면을 교부하지 않고 단지 3일 전 구두로만 통보하였다. 이는 30일 전 해고 예고(乙은 계속 근로기간 6개월로 예외 적용 안됨)를 해야하는 “근로기준법 제26조”를 위반한 것이다. 또한, 시용근로자에게도 강행규정으로 적용되는 “근로기준법 제27조”의 서면통지 의무를 직접적으로 위반하여 절차적 하자를 구성한다. 따라서 본계약 체결 거절에 객관적인 사유(실체적 사유)가 존재하는지 여부를 불문하고, C회사의 구두 통보는 절차상 중대한 하자로 인하여 사법상 효력이 인정되지 않는 무효의 처분이다.

IV. 결론

- C회사가 乙에게 행한 본채용 거절은 실질상 해고에 해당하므로 “근로기준법 제27조”에 따라 구체적인 거절 사유와 시기를 명시한 서면으로 통지하여야 한다. 그러나 C회사는 이를 구두로만 통보하였는바, 이는 강행법규인 서면통지 제도를 위반한 조치로서 절차상 정당성을 상실하여 효력이 없다. 결론적으로 乙에 대한 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 C회사의 조치는 정당하지 않으며 사법상 위법·무효이다.